

# 全球数字贸易争端解决机制发展现状、困境及纾解

漆 彤 \*

**内容提要：**相比传统货物和服务贸易，数字贸易及其争端解决具有明显不同的性质与特征。WTO 争端解决机制因规则滞后和适用性不足而作用受限，区域贸易协定虽尝试构建新规则，但缺乏协调性和强制力，难以形成统一框架。当前，数字贸易争端陷入“规则真空”与“机制失灵”的双重困境，如何构建高效、公平且具有普遍约束力的数字贸易争端解决机制，成为国际社会亟待解决的问题。基于数字贸易的特殊性，设计具有差异性的争端解决程序具有必要性，这一机制既要适当体现数字纪律的规则约束性，也应兼顾数字经济规则发展的适应性与灵活性。在数字贸易领域实体规则尚未统一的情况下，采取争端解决程序法先行的路径，具有一定可行性和必要性。WTO 多边机制与 RTA 多元化争端解决机制各具利弊，多元化是目前现状，多边化是未来方向。

**关键词：**数字贸易 争端解决 世界贸易组织 区域贸易协定

DOI:10.16823/j.cnki.10-1281/d.2025.06.004

数字技术的快速迭代与深度渗透，改变了传统的全球贸易形态，催生了数字贸易的蓬勃发展，并成为全球贸易增长中最具活力的部分和世界经济的重要驱动力。但是，现行国际贸易规则体系在应对数字贸易发展变化上呈现显著滞后性，尚未形成与之适配的规则体系和争端解决框架，数字贸易争端陷入“规则真空”与“机制失灵”的双重困境，无法应对数字贸易特殊性所带来的一系列问题与挑战。本文旨在系统分析数字贸易及其争端解决的特殊性，梳理世界贸易组织（WTO）及区域贸易协定（RTA）在解决数字贸易争端方面的规则与实践困境，进而从国际协调、制度设计和技术应用等维度探索纾解路径，为构建高效、公平且具普遍约束力的数字贸易治理体系提供理论支撑与实践参考。

## 一、数字贸易及其争端解决的特殊性

数字贸易及其争端解决相比传统贸易方式是否具有特殊性，是否存在差异化制度设计的必

\* 漆彤，武汉大学国际法研究所教授。

本文为教育部基地重大项目“我国海外经济利益保护的法理探索与制度创新研究”（22JJD820007）的阶段性成果。

要，是本文首先需要尝试解决的问题。

当前，全球数字贸易发展程度参差不齐，国际社会尚未形成有关“数字贸易”定义的共识。WTO 认为，“数字贸易”涵盖通过数字方式订购或交付的商品和服务贸易，包括电子商务（B2B、B2C）、数字服务（如云计算、流媒体），以及支撑贸易的数字基础设施（如支付系统、物流平台）。〔1〕经济合作与发展组织（OECD）认为，数字贸易是通过数字化的手段实现国际贸易的全流程，包括数字技术赋能的传统贸易（如在线订购实体商品）和纯数字化的交易（如软件、数据服务）。〔2〕联合国贸易与发展会议（UNCTAD）认为，数字贸易的扩展定义包括“通过数字平台中介的贸易”（如亚马逊、阿里巴巴）和“基于数据的贸易”（如人工智能训练数据跨境传输）。〔3〕美国国际贸易委员会（USITC）认为，数字贸易分为数字内容（如电子书、音乐）、数字化交付的服务（如远程教育）和数字化赋能的有形商品贸易（如跨境电商平台交易）三类。〔4〕亚太经合组织（APEC）认为，数字贸易是通过互联网或数字技术进行的跨境商品、服务及数据流动，强调其依赖数字身份、电子支付和信任框架。〔5〕美国有学者认为，数字贸易是依赖数据流动和数字技术实现的贸易形式，其规则需解决隐私、网络安全和竞争政策等问题。〔6〕瑞士有学者认为，数字贸易的独特性在于“无形性”（如数据）和“平台依赖性”（如算法匹配交易），传统贸易规则难以直接适用。〔7〕我国有学者认为，数字贸易治理主要围绕“数据跨境自由流动”“数据存储本地化”和“个人隐私保护”等议题展开。〔8〕归纳以上定义可发现，相比传统贸易，数字贸易呈现技术驱动（如数字交付）、模式多元（涵盖商品/服务/数据）和规则敏感（涉及数据主权）三大特征。

在我国，对数字贸易的认知也处于不断演进之中。商务部发布的《中国数字服务贸易发展报告 2018》认为，数字贸易不同于电子商务，是采用数字技术进行研发、设计、生产，并通过互联网和现代信息技术手段为用户交付的产品及服务，是以数字服务为核心、数字交付为特征的贸易新形态。〔9〕《中国数字贸易发展报告 2021》则进一步将数字贸易分为数字技术贸易、数字产品贸易、数字服务贸易、数据贸易四大领域。其中，数字技术贸易包括软件、通信、大数据、人工

〔1〕 See WTO, *World Trade Report 2018: The Future of World Trade: How Digital Technologies are Transforming Global Commerce*, available at <https://www.wto-ilibrary.org/content/books/9789287045027>, last visited on Aug. 25, 2025.

〔2〕 See OECD, *Handbook on Measuring Digital Trade*, available at <https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3h-Digital%20Trade%20Handbook-E.pdf>, last visited on Aug. 25, 2025.

〔3〕 See UNCTAD, *Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development: For Whom the Data Flow*, available at <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2021>, last visited on Aug. 25, 2025.

〔4〕 See USITC, *Digital Trade in the U.S. and Global Economies, Part 1*, available at <https://www.usitc.gov/publications/332/pub4415.pdf>, last visited on Aug. 25, 2025.

〔5〕 See APEC, *Internet and Digital Economy Roadmap*, available at [https://mddb.apec.org/Documents/2017/SOM/CSOM/17\\_csom\\_006.pdf](https://mddb.apec.org/Documents/2017/SOM/CSOM/17_csom_006.pdf), last visited on Aug. 25, 2025.

〔6〕 See Susan Ariel Aaronson, *Information Please: A Comprehensive Approach to Digital Trade Provisions in NAFTA 2.0*, available at <https://www2.gwu.edu/~iiep/assets/docs/papers/2018WP/AaronsonIIEP2018-12.pdf>, last visited on Aug. 25, 2025.

〔7〕 See Mira Burri, *Towards a New Treaty on Digital Trade*, 55 *Journal of World Trade* 77 (2021).

〔8〕 参见周念利、李玉昊：《全球数字贸易治理体系构建过程中的美欧分歧》，载《理论视野》2017 年第 9 期。

〔9〕 参见商务部：《中国数字服务贸易发展报告 2018》，载 <https://www.199it.com/archives/941255.html>，最后访问时间：2025 年 8 月 25 日。

智能、云计算、区块链、工业互联网等数字技术的跨境贸易；数字产品贸易包括数字游戏、数字出版、数字影视、数字动漫、数字广告、数字音乐等数字内容产品的跨境贸易；数字服务贸易包括跨境电商的平台服务及金融、保险、教育、医疗、知识产权等线上交付的服务；数据贸易主要是数据跨境流动。<sup>〔10〕</sup>中国信息通信研究院发布的《数字贸易发展白皮书（2020年）》认为，数字贸易是指数字技术发挥重要作用的贸易形式，其与传统贸易最大的区别在于贸易方式数字化和贸易对象数字化。其中，贸易方式数字化是指数字技术与国际贸易开展过程深度融合，带来贸易中的数字对接、数字订购、数字交付、数字结算等变化；贸易对象数字化是指以数据形式存在的要素、产品和服务成为重要的贸易标的，导致国际分工从物理世界延伸至数字世界。<sup>〔11〕</sup>

本文认为，准确理解数字贸易，可从其“数字”特征和“贸易”特征入手。所谓“数字”特征，是区分数字贸易与传统贸易的关键。贸易活动的数字特征可能展现为两种方式，即贸易方式的数字化和贸易对象的数字化。前者对应WTO定义方式下的“通过数字方式订购或交付的商品和服务贸易，包括电子商务和数字服务”，后者对应纯数字化的交易（如软件、数据服务）或纯数字产品贸易。所谓“贸易”特征，则意味着并非所有以数字技术（如大数据、人工智能、云计算）为基础的经济活动都属于数字贸易，也并非所有的数据跨境流动都属于数字贸易。因此，非商业目的的跨境数据流动以及纯国内性质的交易，不属于本文所讨论的数字贸易范畴。进行这一区分的作用，在于厘清各自的法律侧重点。例如，数据跨境流动主要侧重合规与安全，如欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）、中国《数据出境安全评估办法》，数字贸易则更加侧重市场开放与规则协调，如《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）中的数字贸易条款。当然，在数字贸易场景下，二者会发生交叉。基于以上分析，数字贸易可界定为不同国家或地区之间进行的以数字技术为基础的商品、服务和要素交换活动，其中既包括贸易方式的数字化，如跨境电子商务，也包括贸易对象的数字化，如以数据形式存在的技术、服务或产品。

作为对传统贸易的升级，数字贸易与传统贸易之间的主要差异体现在贸易方式、贸易对象、资源配置模式和管制手段上的不同，并呈现无形性、技术依赖性和监管碎片化等特征。数字贸易带来的主要挑战，体现于技术、法律、政府三个层面。技术层面的挑战，表现为数字技术的快速发展与规则滞后性之间的矛盾。一方面，人工智能、大数据、云计算、5G等数字技术的快速发展，正在不断重塑数字贸易的形态和模式，推动了贸易成本的降低和生产效率的提升。另一方面，技术迭代的速度远超规则制定的进程，导致现有规则难以适应新兴贸易形态。法律层面的挑战，主要表现为现行国际贸易法律体系在处理数字贸易问题时存在明显不足，缺乏明确的法律规定和有效的监管手段。政府层面的挑战，表现为各国因经济发展水平、文化背景和价值观的差异，对数字贸易规则的立场和诉求各不相同，进而加剧了全球数字贸易规则制定的复杂性。

正是因为数字贸易与传统贸易存在显著差异，数字贸易争端相比传统贸易争端在性质和类型上也有所不同。在主体上，数字贸易争端所涉主体更加多元化，不仅包括企业和消费者，还涉及

〔10〕 参见中华人民共和国商务部服务贸易和商贸服务业司：《中国数字贸易发展报告2021》，载 [https://cif.mofcom.gov.cn/cif/html/upload/20230202091317300\\_中国数字贸易发展报告2021.pdf](https://cif.mofcom.gov.cn/cif/html/upload/20230202091317300_中国数字贸易发展报告2021.pdf)，最后访问时间：2025年8月25日。

〔11〕 参见中国信息通信研究院：《数字贸易发展白皮书（2020）——驱动变革的数字服务贸易》，载 <https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201216506475945126.pdf>，最后访问时间：2025年8月25日。

大量的平台服务提供商、数字内容创作者、数据服务提供商等。在客体上,相比传统贸易的有形商品或传统服务,数字贸易的客体主要是数字产品和服务,如软件、数字内容(音乐、视频、电子书等)、云计算服务、大数据分析等,具有无形性、易复制性、快速传播性等特点,其价值和质量的评估更加复杂,且往往伴随知识产权、数据安全等问题。在交易方式上,传统贸易主要通过线下渠道进行,数字贸易则主要通过互联网和数字平台进行,交易过程高度数字化和自动化,交易方式更加便捷、快速,且不受时间和空间的限制,但是,这种快速的交易过程也增加了监管和取证的难度。在规则适用上,传统贸易的法律框架相对成熟,数字贸易的法律框架则尚处于不断发展和完善中,目前缺乏统一的国际规则,各国根据自身利益和政策制定的数字贸易规则之间存在差异和冲突,增加了法律适用的复杂性。在法律关注点上,传统贸易争端的焦点主要在于市场准入、价格歧视、产品质量标准等问题,数字贸易争端所涉及的技术和法律问题更加复杂,除了传统的贸易政策问题外,还涉及数据与隐私的保护、数据跨境流动的监管、数字知识产权保护、网络安全、数字平台监管、数字税、技术性证据和证据标准等诸多新兴问题。在数字贸易争端的类型上,可按主体、内容和解决机制等多种方式进行划分。例如,按主体可分为国家间争端(如美国诉中国电子支付服务案)、政府与企业争端(如欧盟对谷歌的反垄断罚款)、企业间争端(如苹果与 Epic Games 的应用商店抽成争议)、用户/消费者争端(如跨境数据隐私诉讼)。如按争议内容,可划分为:市场准入壁垒,如外资限制、数据本地化要求、数据流动与隐私(如欧盟—美国“隐私盾”协议失效);数字税与关税,如法国对谷歌、亚马逊征收数字服务税;知识产权保护,如美国指责中国未有效打击影视盗版;技术标准与合规,如华为 5G 设备因国家安全担忧被多国限制。如按解决机制,可划分为:多边机制,如 WTO 争端解决机制;区域/双边协定,如 CPTPP、《美墨加协定》(USMCA)、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP) 中的数字贸易条款;国内司法诉讼或国际仲裁,如 TikTok 起诉美国政府的行政禁令;企业自律协商,如平台规则或行业协议等。

数字贸易争端的特殊性与复杂性,尤其体现在国家、企业、用户等多主体参与,以及法律、技术、经济等多维度的冲突上,需要区别于传统贸易争端并作出相应的规则调适。对此,国内外学者均有相关论述。例如,日本有学者认为,WTO 协定下的传统贸易规则与电子商务相关贸易协定下数字贸易规则不同的性质及其背后的技术社会差异,导致依据这些规则产生的争端性质存在显著差异。<sup>[12]</sup> 有学者指出:美国在早期曾试图将数字贸易嵌入 WTO 框架中,但《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP) 的出台表明美国已很大程度上从将数字贸易视为一个传统贸易问题转变为承认其独特的数字性质并相应地调整规则;TPP 从侧重贸易和政府监管向适应数字贸易特点及企业监管转变,对未来贸易协定有重要启示。<sup>[13]</sup> 针对数字贸易及其争端解决所展现出的特殊性,现有国际规则体系是否对此作出了足够的回应和必要的调整? 本文第二、三部分将结合多边和区域层面的数字贸易规则发展及其争端解决实践,分析当前国际法在数字贸易争端解决机制方面的发展

[12] See Yuka Fukunaga, *Are Digital Trade Disputes “Trade Disputes”?*, in Shin-yi Peng, Ching-Fu Lin & Thomas Streinz eds., *Artificial Intelligence and International Economic Law Disruption, Regulation, and Reconfiguration*, Cambridge University Press, 2021, pp. 155–172.

[13] See Henry Gao, *Regulation of Digital Trade in US Free Trade Agreements: From Trade Regulation to Digital Regulation*, 45 *Legal Issues of Economic Integration* 47 (2018).



现状、问题及不足。

## 二、WTO 框架下数字贸易争端的有限解决

### （一）WTO 框架下的数字贸易规则及相关议题谈判

1994 年乌拉圭回合通过的《WTO 协定》是国际贸易法的基础，为国际经贸治理提供了一整套规范体系。在乌拉圭回合谈判之时，国际贸易以货物贸易为主，服务贸易刚刚起步，互联网产业尚处于萌芽阶段，大规模的数字贸易还没有出现，因此 WTO 规则体系中没有专门涉及数字贸易的条款。<sup>〔14〕</sup> 尽管彼时 WTO 并未特别关注数字贸易并作出系统性的专门规定，但嗣后实践表明其规则仍部分适用于数字贸易领域。WTO 现有规则中，与数字贸易相关的条款主要分散在《1994 年关贸总协定》（GATT 1994）、《服务贸易总协定》（GATS）和少数专门协定中。例如，GATT 第 1 条最惠国待遇条款和第 3 条国民待遇条款可能适用于通过物理载体如 CD、DVD 传输的数字产品。GATS 与数字贸易的联系更为紧密，其虽未明确区分数字化与非数字化服务，但已被争端解决实践证实可适用于数字服务（如云计算、在线娱乐）的跨境提供；在 GATS 所涵盖的 12 个服务贸易部门中，第 2 个部门（通信服务）下的子部门 2.C（增值电信服务）包含“在线信息和数据检索”和“在线信息和/或数据处理（包括交易处理）”；GATS 第 14 条所规定的一般例外条款亦可能被援引以限制数据流动（如隐私保护）。其他协定，如《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）可被用于保护软件著作权，但对人工智能生成内容、数据所有权等新议题无规定，《基础电信协定》规范电信基础设施开放，但未解决互联网接入歧视（如“网络中立性”）问题，《信息技术协定》（ITA）仅降低硬件产品（如服务器、路由器）关税，未涉及数据、软件或数字服务规则，《贸易便利化协定》（TFA）、《原产地规则》涉及进出口过程中的各类贸易文件（如原产地证书、进口商声明、装箱单等），数字技术的广泛使用可能极大地促进此类文件中所包含信息的电子交流，在贸易技术壁垒（TBT）方面，数字和相关技术的法规、标准已成为 TBT 委员会的经常性讨论内容。整体而言，形成于前互联网时代的 WTO 规则体系没有考虑到数字贸易的复杂性，其对于数字贸易的适用性需要经过分析论证。

尽管缺乏数字贸易的专门规则，WTO 早已察觉数字贸易对国际贸易和经济全球化的重要性，但相关议题谈判受技术变革、地缘政治和发展差异多重影响，迄今未取得实质性成果。1996 年的 WTO 第一届部长级会议就正式提及了电子商务议题。1998 年 WTO 第二届部长级会议通过了《全球电子商务宣言》，认识到电子商务对贸易的潜在影响，并同意暂不对电子传输征收关税（即“电子传输关税暂缓征收”）。同时，WTO 总理事会设立“电子商务工作计划”，要求各成员研究电子商务相关的贸易规则。<sup>〔15〕</sup> 1998 年至 2016 年间，WTO 成员通过“电子商务工作计划”定期讨论电子商务的定义、分类、税收、发展中国家的参与等问题，但未形成具体规则。2017 年 12 月，在 WTO 第十一届部长级会议期间，71 个成员（后增至 90 多个）共同发表《关

〔14〕 参见谭观福：《国际经贸规则视域下中国对数字贸易的规制》，载《河北法学》2023 年第 12 期。

〔15〕 See WTO, *Work Programme on Electronic Commerce*, available at <https://www.wto.ru/upload/medialibrary/046/Work%20Programme%20on%20Electronic%20Commerce.pdf>, last visited on August 25 2025.

于电子商务的联合声明》，同意启动电子商务议题的谈判，目标是制定多边规则，谈判目标聚焦数据流动、隐私保护、电子签名、消费者权益、数字产品非歧视待遇等新兴议题，同时兼顾发展中国家的需求。<sup>〔16〕</sup> 2019 年起，谈判进入实质性阶段，成员提交提案并形成合并文本草案。2020 年后，谈判因新冠疫情和成员分歧（如美欧对数据规则的立场差异、发展中国家对政策空间的诉求）而放缓。2023 年，谈判方表示力争在 2024 年前完成部分议题，但核心分歧仍未解决。2024 年 2 月，WTO 第十三届部长级会议前，谈判方就部分条款达成初步共识，如电子签名、电子合同等“低争议”议题，但数据相关规则仍悬而未决。2025 年 4 月的最新一轮谈判中，新加坡大使指出，这将是自 1996 年以来第一套基线数字贸易规则，在监管日益碎片化的背景下，它将通过提供更高的法律可预测性和确定性，虽然取得了很大进展，但还没有越过终点线。<sup>〔17〕</sup> 总体来看，WTO 电子商务谈判反映了数字经济时代的规则博弈，其进程受技术变革、地缘政治和发展差异多重影响。未来能否达成全面协议，取决于成员能否平衡创新、发展与主权诉求。

## （二）WTO 与数字贸易有关的争端解决实践

从 WTO 争端解决实践来看，已有多起涉及数字内容或数字化交付的案件进入争端解决程序。WTO 成立早期的许多案件，如 1996 年美国诉日本有关录音的措施案（DS28）、1996 年美国诉加拿大有关期刊的若干措施案（DS31）、1998 年欧盟诉加拿大影响电影发行服务措施案（DS117）、1999 年欧盟诉美国版权法第 110（5）条款案（DS160）等，均与录音、期刊、电影、音乐等贸易内容有关，尽管这一时期的相关产品不完全表现为数字载体，但亦表明 WTO 多边规则并不排除对以数字内容为对象的贸易争端的适用可能。例如，在 2007 年美国诉中国影响部分出版物和音像娱乐产品交易权和发行服务措施案（DS363）中，尽管中国对录音分销服务作出承诺时在线分销并非主流，专家组和上诉机构都认为录音制品的分销包括以电子方式进行的在线分销形式，并裁定中国禁止外资从事电子形式录音制品分销的规定与 GATS 第 17 条国民待遇义务不一致。<sup>〔18〕</sup> 值得注意的是，与早期争端主要集中于数字内容的产品进口限制不同，晚近 WTO 受理了多起涉及数字技术的出口限制争端，表明数字贸易争端的类型正在发生转变。例如，在 2019 年韩国诉日本产品及技术出口相关措施案（DS590）中，韩国要求就日本采取的限制出口氟化聚酰亚胺、光刻胶聚合物和氟化氢及其相关技术的措施进行磋商，这些产品和技术主要用于智能手机、电视显示器和半导体的生产。在 2022 年的中国诉美国某些半导体和其他产品、服务和技术措施案（DS615）中，中国要求就美国对运往中国或与中国相关的某些先进计算半导体芯片、超级计算机物项、半导体制造物项和其他物项及其相关服务和技术的贸易限制措施与美方进行磋商，美国则以被质疑的措施涉及不宜审查或无法通过 WTO 争端解决的国家安全问题为抗辩。<sup>〔19〕</sup>

〔16〕 See WTO, *Work Programme on Electronic Commerce*, available at <https://www.mfat.govt.nz/assets/Trade-agreements/WTO-e-commerce-negotiations/WORK-PROGRAMME-ON-ELECTRONIC-COMMERCE-Ministerial-Decision-December-2017.pdf>, last visited on Aug. 25, 2025.

〔17〕 See WTO, *E-commerce Negotiators Finalize “Technical Discussions” and Outline Next Steps*, available at [https://www.wto.org/english/news\\_e/news24\\_e/ecom\\_25apr24\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/ecom_25apr24_e.htm), last visited on Aug. 25, 2025.

〔18〕 案件详情可参见 [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds363\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds363_e.htm)，最后访问时间：2025 年 8 月 25 日。

〔19〕 案件详情可参见 [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds615\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds615_e.htm)，最后访问时间：2025 年 8 月 25 日。

在数字化交付类争端解决实践中，最为经典的案例是 2005 年的“美国赌博案”，其被认为是跨境数字服务贸易的第一案。专家组和上诉机构毫不犹豫地将 GATS 规则适用于跨境电子服务交付，裁定美国 GATS 承诺表中的特定分部门包括了对通过互联网提供赌博服务的具体承诺。专家组和上诉机构将网络赌博服务认定为跨境交付，并适用了非常严格的非歧视标准，阐明了 GATS 第 14 条一般例外条款的适用性。该案在一定程度上缓解了 WTO 规则体系能否适用于数字贸易的不确定性。在涉及数字化交付中的市场准入问题上，也存在不少案例。例如，在加拿大诉中国影响金融信息服务和外国金融信息提供者的措施案（DS378）中，欧盟认为外国金融信息供应商不被允许直接提供订阅服务而只能通过新华社指定的代理人开展业务，涉嫌违反中国在《服务贸易总协定》《TRIPS 协定》和《中国加入议定书》项下义务。<sup>〔20〕</sup>在美国诉中国电子支付服务案（DS413）中，美国指控中国对支付卡交易的电子支付服务以及这些服务的供应商施加某些限制和要求，涉嫌违反 GATS 第 16 条市场准入和第 17 条国民待遇义务。<sup>〔21〕</sup>中国接受裁决后修改相关规章，取消统一银联标识要求，但保留对跨境支付服务的限制。2024 年中国进一步提交提案，呼吁 WTO 加强电子支付便利化合作，反映发展中国家诉求。<sup>〔22〕</sup>中国电子支付案也是 WTO 框架下数字贸易争端的标志性案件，反映出 WTO 现有规则对新兴技术的适应性不足及发展中国家在规则制定中的弱势地位。

### （三）WTO 在解决数字贸易争端方面的问题与不足

尽管争端解决实践表明 WTO 规则体系可部分适用于数字贸易领域，但是 WTO 规则与数字贸易的严重脱节，以及进展缓慢的电子商务谈判，表明多边贸易体制在数字贸易治理方面存在严重制度供给不足。数字贸易的复杂性与新兴性，使其难以被传统贸易规则所完全涵盖，这些问题严重制约了 WTO 在数字时代国际贸易争端解决中的作用发挥。

首先，WTO 数字贸易争端解决面临实体规则的严重缺失。WTO 争端解决机制的适用范围限于协定涵盖领域，而现有规则体系主要是在传统贸易模式下形成的，在数字贸易领域存在明显的实体规则真空，因此，成员方的争议措施可能因规则缺失而难以适用争端解决机制。例如，在非歧视待遇方面，一些国家可能通过对外国数字企业征收歧视性税收来保护本国数字产业，如法国对谷歌、亚马逊等企业征收数字服务税，而 WTO 税收规则并未明确涵盖数字税类型，这些措施在现有规则下很难被认定为违反国民待遇或最惠国待遇原则。在市场准入方面，WTO 规则可以适用于不同贸易类型，但并不意味着 WTO 成员的贸易承诺可以自动拓展到所有的数字贸易部门。例如，GATS 虽然规定了成员方应逐步开放服务市场，但对于数字产品进入市场应满足的具体条件、是否允许限制数字产品的进口数量等关键问题并未作出明确规定，一些新型数字产品和数字服务可能难以被成员的 GATS 承诺表所涵盖，这些部门的市场开放需要经过成员重新谈判并作出承诺。在国内监管方面，一些国家要求社交媒体平台对算法透明度及推荐内容承担法律责

〔20〕 案件详情参见 [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds378\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds378_e.htm)，最后访问日期：2025 年 8 月 25 日。

〔21〕 案件详情参见 [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds413\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds413_e.htm)，最后访问日期：2025 年 8 月 25 日。

〔22〕 See WTO News, *Members Discuss Harnessing Benefits of Fast-Growing Services Trade for Their Economies*, available at [https://www.wto.org/english/news\\_e/news24\\_e/serv\\_06dec24\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/serv_06dec24_e.htm), last visited on Aug. 25, 2025.

任，如欧盟《数字服务法》中的内容审核义务，这类措施可能涉及技术中立性问题，但 WTO 缺乏相关规则约束。在例外援引方面，一些国家可能基于“公共道德”（GATS 第 14 条）或“国家安全”（GATT 第 21 条）考量，通过数据本地化、跨境数据流动、源代码强制披露等方面的措施对数字贸易加以限制，如俄罗斯的《个人数据本地化法》以及社交平台封锁，这些敏感议题与数据主权密切相关，往往被成员视为域内政策空间，WTO 规则亦未涉及这些领域。实体规则的严重缺失，导致 WTO 成员方在制定数字贸易政策时缺乏有效的外部约束标准，容易引发歧视性待遇和贸易保护主义行为，进而频繁产生数字贸易争端，相关措施即便被诉诸争端解决机制，由于缺乏明确的规则支撑，WTO 争端解决机构也很难进行裁决。

其次，现有规则如何适用于数字贸易存在定性模糊和解释困境。WTO 既有的与数字贸易有关的规则非常有限且零散，无法实现足够的法律确定性。正如有学者所指出，随着技术的融合以及数字产品内容在不同技术中变得越来越便携，货物和服务之间的界限以及软件、电信和视听服务之间的界限日益模糊，这使得当前的贸易规则对数字贸易的适用充满了不确定性。<sup>〔23〕</sup> 在 WTO 的框架下，数字产品（如软件）属于“货物”还是“服务”仍存分歧。根据《服务贸易总协定》，服务被定义为“任何部门的任何服务”，但这种宽泛的定义在面对数字产品时显得捉襟见肘。在判断数字产品应由 GATS 还是 GATT 调整时，各成员方容易产生分歧。一些成员方可能倾向于将数字产品归入货物范畴，以适用 GATT 中关于关税、贸易壁垒的规则；而另一些成员方则可能主张其属于服务，从而依据 GATS 中的市场准入、国民待遇等条款来处理相关问题。定性上的模糊也为数字贸易争端的解决带来了巨大的不确定性，使得争端解决机构在确定适用规则时面临重重困难。例如，在加拿大期刊案中，上诉机构最终认定线上分销期刊和国内期刊属于“竞争或可替代产品”，属于货物范畴，受 GATT 规制。而在中美出版物和视听产品案以及赌博案中，录音产品的网上分销和网络赌博被认定为服务，受 GATS 规制。WTO 现有规则在解释数字贸易相关条款时也存在诸多困境。以电子商务为例，GATS 中仅在附件 1B 中对“通过电子手段供应的服务”进行了简要提及，但并未对其范围、特征等进行明确界定。随着数字技术的不断发展，新的数字贸易模式如云计算服务、大数据交易等不断涌现，这些新兴模式很难在现有规则的字面含义中找到明确对应的解释。当成员方之间因这些新兴数字贸易模式产生争端时，争端解决机构往往需要在缺乏明确规则指引的情况下，依据一般原则和以往案例来进行解释和裁决。然而，这种解释方式容易受到不同成员方利益诉求的影响，导致解释结果的不一致性和主观性增强。例如，在不同国家的司法实践中，对于数据跨境流动是否构成服务贸易的“供应”存在不同的理解，一些国家可能认为只有当数据被用于商业目的且产生经济收益时才构成服务供应，而另一些国家则可能持更宽泛的观点，认为只要数据跨境流动就涉及服务贸易。这种解释上的困境使 WTO 在处理数字贸易争端时难以形成统一、权威的裁决标准，影响了争端解决的公正性和权威性。如果争端解决机构强行对规则进行扩张解释，可能超越缔约方预期的义务范围而引发质疑。因此，有学者提出，数字产品及服务贸易争端解决需要从传统贸易争端解决机制中剥离出来，因为它们具有特殊性，例如涉及计算设施位置本地化、政府数据开放、跨境数据流动自由化等敏感问题。<sup>〔24〕</sup>

〔23〕 参见谭观福：《国际经贸规则视域下中国对数字贸易的规制》，载《河北法学》2023 年第 12 期。

〔24〕 参见中国法学会世界贸易组织法研究会：《数字贸易规则建构与完善》，载 <https://wto.chinalaw.org.cn/portal/article/index/id/194.html>，最后访问时间：2025 年 8 月 25 日。



最后，数字贸易争端的解决面临诸多程序障碍。自 2019 年以来，WTO 争端解决机制因上诉机构停摆而陷入瘫痪，争端解决程序可能无法完成终裁，导致一些数字贸易争端（如美欧数据隐私冲突）长期悬置。即便上诉机构恢复运作，这一机制在面对数字贸易争端时也存在诸多的程序障碍。第一，WTO 争端解决的时效性问题较为突出。其平均 2~3 年的争端解决时长，与数字贸易快速迭代的特性不相匹配。数字贸易的发展速度极快，新的技术和商业模式不断涌现，而 WTO 争端解决程序相对繁琐，从争端的提起、磋商、专家组的设立和报告的发布，再到上诉机构的审查等环节，往往需要耗费较长的时间。这使得在数字贸易争端解决过程中，当专家组或上诉机构最终作出裁决时，相关的数字贸易模式可能已经发生重大变化，甚至已经被新的技术所取代。第二，数字贸易争端解决程序中可能存在电子证据收集和认定上的难题。数字贸易争端常涉及企业数据隐私，证据获取受国内法限制。数字贸易还可能涉及大量的电子数据、算法等复杂的技术内容，这些证据的收集和固定难度较大，且容易被篡改和伪造。同时，不同国家对于电子证据的法律效力和认定标准也存在差异，这使得在争端解决过程中，专家组和上诉机构在对证据进行审查和认定时面临诸多困难，进而影响裁决的准确性和公正性。第三，数字贸易争端往往涉及数据主权冲突，对相关争端的管辖权可能会受到质疑。成员方关于数据本地化或隐私保护的法律法规可能被诉为贸易壁垒，但成员方可能会利用国家安全例外规避 WTO 审查（如美国对 TikTok 的制裁），WTO 缺乏平衡贸易自由与国内监管权（如欧盟 GDPR）的标准。第四，裁决可能存在执行与报复困难。一方面，传统贸易报复（如加征关税）对数字服务或数据流动的制裁效果有限，且可能引发技术对抗（如网络封锁）。另一方面，与传统贸易主要依靠政府监管不同，数字贸易很大程度上依赖平台企业，甚至将监管负担转移给了私人公司，WTO 裁决缺乏约束私营主体（如要求调整算法）的相关机制。<sup>[25]</sup> 第五，基于数字技术复杂性，WTO 争端解决机构可能缺乏处理技术性议题（如人工智能歧视、区块链交易）的专业能力，需要寻求外部支持。

### 三、区域贸易协定数字贸易争端的碎片化解决

#### （一）区域贸易协定在发展数字贸易规则方面的实践

WTO 数字贸易规则的缺失，是区域贸易协定推动数字贸易谈判的动因，区域贸易协定逐渐成为数字贸易规则谈判的重要场所。相对于成立于三十年前的 WTO 而言，晚近发展起来的区域贸易协定见证了数字贸易的兴起，且由于成员数量相对较少，在发展数字贸易规则方面更易于达成一致。因此，近年来全球范围内与数字贸易议题相关的贸易协定数量持续增加，议题范围从传统的电子商务、无纸化贸易、知识产权等领域逐渐延伸到消费者隐私保护、数据跨境流动、数字产品非歧视性待遇、数字技术治理、数字平台治理等新兴领域。<sup>[26]</sup> 作为超越 WTO 多边平台的

[25] See Henry Gao, *Regulation of Digital Trade in US Free Trade Agreements: From Trade Regulation to Digital Regulation*, 45 *Legal Issues of Economic Integration* 47 (2018).

[26] 参见中华人民共和国商务部：《中国数字贸易发展报告 2024》，载 [https://fms.mofcom.gov.cn/cms\\_files/filemanager/10364010/attach/20249/d54a62e9ce31430aa0054a1d59fc0abf.pdf?fileName=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%95%B0%E5%AD%97%E8%B4%B8%E6%98%93%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%8A%A5%E5%91%8A2024.pdf](https://fms.mofcom.gov.cn/cms_files/filemanager/10364010/attach/20249/d54a62e9ce31430aa0054a1d59fc0abf.pdf?fileName=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%95%B0%E5%AD%97%E8%B4%B8%E6%98%93%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%8A%A5%E5%91%8A2024.pdf)，最后访问时间：2025 年 8 月 25 日。

高标准规则，一些具有代表性的区域贸易协定如 CPTPP、USMCA、RCEP、《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)，在数字贸易规则上走得更远。这些协定大多包含数字贸易争端解决方面的规定，以缓解因数字经济发展而不断加剧的数字贸易争端解决困境。但是，不同国家和地区在全球数字贸易中有不同的角色分工且处于不同的发展阶段，数字能力建设方面存在很大差别，具有各自的利益诉求。因此，各协定所主张的数字贸易规则既有共同点，也存在显著差异，“多样性”和“多元化”特征明显，反映了不同经济体对数字贸易的不同监管取向和利益诉求。

通过比较可以发现，各主要区域贸易协定在促进数字贸易自由化方面具有共同点，多数协定（如 CPTPP、USMCA、RCEP）原则上支持数据跨境自由流动，但允许例外（如公共安全、隐私保护）；在电子传输免关税方面，CPTPP、USMCA、RCEP 均永久禁止对电子传输（如软件、音乐）征收关税；在电子签名与认证方面，大多承认电子签名的法律效力（如 RCEP 第 12.6 条、USMCA 第 19.6 条）。与此同时，区域贸易协定中的数字贸易规则也呈现出类型化的特点，并被学者们划分为美国、欧盟以及发展中国家等不同范式。<sup>〔27〕</sup> 基于主导国及参与国的不同，各协定中的数字贸易规则也存在诸多差异，呈现多样化特征。以数据治理为例，CPTPP、USMCA 严格限制数据本地化（如 CPTPP 第 14.13 条、USMCA 第 19.12 条），仅允许有限例外（如金融监管），RCEP 允许成员方基于“正当公共政策目标”限制数据流动（第 12.15 条）。在隐私保护方面，CPTPP 鼓励国际标准，USMCA 要求成员方制定隐私保护法律，并鼓励兼容性（第 19.8 条），RCEP 仅原则性提及隐私保护，无具体约束力条款，《欧盟—日本经济伙伴关系协定》（欧盟—日本 EPA）则直接援引 GDPR，要求高标准隐私保护。在源代码与算法透明度方面，USMCA 禁止强制披露源代码和算法（第 19.16 条），但排除政府采购和金融监管，CPTPP 采取了类似规则，但允许更多例外（如司法程序），RCEP 则完全未涉及源代码问题。在平台责任与内容监管方面，USMCA 明确要求平台对用户生成内容免责（第 19.17 条“避风港”原则），类似美国《通信规范法》第 230 条，CPTPP/RCEP 则未明确规定平台责任，留待国内法处理。

## （二）区域贸易协定在数字贸易争端解决上的安排

对于数字贸易的争端解决，各区域贸易协定之间的规则差异亦非常明显。CPTPP 争端解决机制明确涵盖电子商务章节（第 14 章）的争端，包括数据流动、本地化要求、电子签名等。解决程序上要求成员方先磋商解决（第 28.5 条），若磋商失败可请求设立专家组，裁决具有法律约束力，允许技术专家介入，在涉及技术性问题时可咨询专家（如数据安全），允许对“非违反之诉”即未违反协定但损害利益的措施提起争端解决（第 28.3 条）。USMCA 争端解决机制可适用于数字贸易章节（第 19 章）的争端，如数据本地化、平台责任等，但排除部分敏感领域的数字服务（如墨西哥金融数据）适用特殊争端程序。程序上采取先磋商，后由自由贸易委员会调解，最终可诉诸专家组的分阶段处理方案，且规定了对数字贸易争端设置更短时限要求（如专家组须在 120 天内提交报告），允许胜诉方对拒不执行方加征关税（第 31 章）。RCEP 第 19 章争端解决机制可适用于电子商务章节（第 12 章）的争端，但第 12 章设置了诸多例外，如数据流动、数据本地化等措施被明确排除在争端解决机制外（第 12.16.2 条），仅允许对电子签名和认证（第 12.6

〔27〕 参见谭观福：《国际经贸规则视域下中国对数字贸易的规制》，载《河北法学》2023 年第 12 期。

条)、无纸化贸易(第12.5条)、在线消费者保护(第12.7条)、网络安全合作(第12.13条)等少数条款提起争端解决。即使对可诉条款(如电子签名),也需满足严格的适用条件,如双方同意,申诉方需与被告方另行协商是否适用第19章程序(第12.17.3条)。在裁决结果的效力上,RCEP的争端解决结果无法律强制力。因此,RCEP的数字贸易争端具有更强的自愿性、灵活性,无强制仲裁,更多依赖政治协商。《欧盟—日本EPA》则采取了混合模式,一般争端解决机制(第16章)适用于数字条款,但隐私争议除外,如GDPR合规只能交由欧盟法院(CJEU)管辖。关于主要区域贸易协定数字贸易争端解决条款的比较请见表1。

表 1 主要区域贸易协定数字贸易争端解决条款横向比较

| 维度     | CPTPP        | USMCA          | RCEP     | 欧盟—日本 EPA      |
|--------|--------------|----------------|----------|----------------|
| 法律约束力  | 强(专家组裁决必须执行) | 强(允许贸易报复)      | 弱(自愿执行)  | 中(欧盟法院优先)      |
| 适用范围   | 全面覆盖数字条款     | 覆盖数字条款,但排除金融数据 | 部分排除敏感领域 | 数字条款从属于服务与投资规则 |
| 程序速度   | 常规时限         | 快速通道(120天)     | 无明确时限    | 常规时限           |
| 执行机制   | 贸易制裁(如关税)    | 贸易制裁           | 无强制措施    | 联合委员会协调        |
| 隐私争端处理 | 未单独规定        | 未单独规定          | 未单独规定    | 欧盟法院专属管辖       |

(三) 区域贸易协定在解决数字贸易争端方面的问题与不足

区域贸易协定在数字贸易争端解决问题上呈现多样性、碎片化、管辖权重叠、执行力弱等特征,增加了贸易成本和不确定性。

第一,各国在数字贸易领域的利益诉求存在较大差异,这给区域贸易协定的谈判和数字贸易争端的解决带来了困难。发达国家通常更关注数字贸易的自由化和数据跨境流动的便利化,以维护其在数字技术和产业方面的优势地位;而发展中国家则更注重数字贸易中的隐私保护、数据安全以及本国数字产业的发展空间,担心过度自由化会对其国内产业造成冲击。这种利益诉求的差异使得在区域贸易协定谈判中难以达成一致意见,也导致在解决数字贸易争端时难以找到各方都能接受的解决方案。

第二,碎片化的数字贸易规则格局导致市场的分割,带来规则的冲突和竞合。众多区域贸易协定中的数字贸易条款错综复杂,相互冲突和竞合的现象时有发生,“意大利面碗效应”明显。这种碎片化的规则格局不仅使各国难以适从,亦导致企业在多区域运营时面临规则冲突,在不同区域市场面临不同的合规要求(如数据本地化要求),增加了企业的合规成本,阻碍了数字贸易的自由化和便利。

第三,不同区域贸易协定的争端解决机制之间以及与WTO争端解决机制之间存在管辖权冲突和不确定性。由于数字贸易的跨境性和复杂性,同一数字贸易争端可能涉及多个区域贸易协定的管辖权。一些成员同时加入了多个区域贸易协定,例如RCEP与CPTPP成员存在重叠,而这些成员大多又都是WTO成员。当数字贸易争端涉及多个协定时,难以确定由哪个协定项下的争端解决机制来管辖。争端当事方基于自身的立场和诉求考量,可能在具体争端中展现出不同的场所选择倾向,难以达成一致,甚至出现挑选法院(forum shopping)的情形。加之不同协定的数字贸易实体规则差异,不同的争端解决机构对同一案件作出不一致的裁决亦有可能。这种管辖权

上的重叠和冲突，可能导致争端解决的拖延和效率低下，增加了争端解决的复杂性和成本。

第四，即使区域贸易协定的争端解决机构作出了裁决，在执行环节也可能面临执行力度不足的问题。<sup>〔28〕</sup>部分成员方可能出于自身利益考虑，不积极履行或拒绝履行裁决结果，而整体上区域贸易协定的执行监督机制相对薄弱，缺乏有效的强制手段，当事方的合法权益难以得到及时有效的维护。例如，对于不履行裁决的成员，协定可能没有明确规定相应的制裁措施，这使得执行机制的威慑力不足，影响了争端解决机制的权威性和有效性。正是因为存在制度框架不完善、执行力度不足等问题，区域贸易协定争端解决机制数量多但实践中的实际使用案例很少。<sup>〔29〕</sup>

#### 四、全球数字贸易争端解决机制的体系性完善

##### （一）针对数字贸易争端解决的特殊性进行差异化制度设计

数字贸易与传统贸易在多个方面存在显著差异，数字贸易的复杂性和多样性使传统的争端解决机制难以完全适应其需求。数字贸易争端解决机制的特殊性突出表现为：（1）技术依赖性。数字贸易高度依赖网络信息技术，这种技术依赖性使数字贸易争端往往涉及复杂的技术问题，如数据跨境流动、隐私保护、网络安全等，这些问题在传统贸易中并不涉及。（2）虚拟性与无形性。数字产品和服务的虚拟性和无形性，使其在贸易过程中的界定和监管更加困难。例如，数字产品的知识产权保护、数字服务的市场准入等问题都难以用传统贸易规则来衡量和规范。（3）快速变化性。数字技术的快速创新和新商业模式的不断涌现，使数字贸易的规则需求也在不断变化。传统的争端解决机制往往难以跟上这种快速变化的步伐，导致规则的滞后性和不确定性增加。（4）数字规则的国别差异性。数字贸易争端涉及多个国家和地区，数据的跨境流动、数字服务的远程提供等对传统的地域管辖和规则适用形成挑战。不同于传统贸易领域各国的规则统一化已达到相当的高度，基本形成大同小异的做法，在数字治理上，各国的立场及规则差异巨大，无形中增加了争端解决的复杂性和协调难度。

为更好地适应数字贸易的发展需求，数字贸易争端解决机制需要在考虑其特殊性的基础上进行必要的差异化设计。例如，针对数字贸易争端的技术依赖性，争端解决机制应体现更多的专业化色彩，如设立专门性的数字贸易法庭或建立常态化的外部专家咨询机制；针对数字贸易争端的快速变化，争端解决机制应展现更多的适应性和灵活性，如倡导混合式的争端解决模式。当前，高度司法化的国际争端解决机制正面临危机，<sup>〔30〕</sup>混合模式体现了约束力与灵活性的平衡，既可发挥司法的价值引导功能，又可以利益冲突调和的方式弥补实体规则的缺失，从而更好地弥合立场分歧，最大程度地化解争端。<sup>〔31〕</sup>实践层面上，在区域贸易协定劳工争端解决机制的设计上，

〔28〕 See Marc D. Froese, *Digital Trade and Dispute Settlement in RTAs: An Evolving Standard?* 53 *Journal of World Trade* 783 (2019).

〔29〕 See Claude Chase, Alan Yanovich, Jo-Ann Crawford & Pamela Ugaz, *Mapping of Dispute Settlement Mechanisms in Regional Trade Agreements: Innovative or Variations on a Theme?*, available at <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/80057/1/749852216.pdf>, last visited on Aug. 25, 2025.

〔30〕 参见果沈洁、肖冰：《国际争端解决机制的司法化困境及其改革进路》，载《外交评论（外交学院学报）》2023年第5期。

〔31〕 参见万晓格：《数字贸易争端解决程序设计研究》，载《中国国际私法与比较法年刊》第26卷，法律出版社2021年版，第253页。



欧盟已发展出不同于美国“刚性”做法的“柔性”范式，亦可作为参照。<sup>〔32〕</sup>为加强数字贸易的制度供给，消除制约数字贸易发展的体制、机制性障碍，可以考虑在WTO框架内建立专门的数字贸易争端解决机构并引入多方利益相关者机制。该机构应具备专业的技术背景和法律知识，专门负责数字贸易争端的调查和裁决。同时，数字贸易的复杂性要求在争端解决过程中引入政府以外的多方利益相关者，如企业、技术专家和消费者等。通过多方协商和合作，可以更好地平衡各方利益，提高争端解决的公正性和有效性。

## （二）数字贸易争端解决的实体法困境不影响程序法先行

目前，全球数字贸易的实体规则存在严重的多边不足并呈现区域碎片化状态，这给数字贸易争端解决带来了巨大挑战。WTO现有的规则体系在数字贸易领域存在大量空白，如数据跨境流动、数字知识产权保护等关键问题缺乏明确的规则。这种规则空白使得在处理数字贸易争端时，争端解决机构往往难以找到明确的法律依据。随着数字技术的快速发展，新的数字贸易模式和问题不断涌现，如人工智能、区块链等新兴技术的应用。现有的实体规则难以涵盖这些新兴问题，导致在处理相关争端时缺乏有效的规则指引。毫无疑问，WTO应加快制定专门的数字贸易规则，明确数字产品的定义、数据跨境流动的条件、数字知识产权保护等关键问题。这些规则应具有灵活性和前瞻性，能够适应数字技术的快速变化。但是，WTO的电子商务谈判目前尚未取得成功，各国在数字治理的其他领域仍存在巨大差异，这意味着数字贸易争端解决可能在较长时间内仍将面临缺乏统一的实体规则的窘境。

数字贸易争端解决是否必须遵循“先实体后程序”的顺序？在这一问题上，国际投资法领域的实践具有一定的借鉴意义。众所周知，国际投资领域缺乏多边实体性公约，主要的法律渊源是为数众多的双边投资协定和含投资章节的自由贸易协定，“意大利面碗效应”和规则碎片化的现象十分严重，但这似乎并未妨碍国际投资仲裁机制在解决投资争端方面发挥着越来越重要的作用。尽管存在裁决缺乏一致性等各种弊端，但是国际投资仲裁机制受理的案件数量一直在攀升。国际投资领域“先程序后实体”的争端解决发展路径，一定程度上说明，即便实体规则存在不足，程序法的完善对于争端解决仍然具有重要意义。通过为争端解决提供基本的框架和流程，程序法可以引导各方在争端解决过程中遵循一定的规则和程序，从而减少争端的复杂性和不确定性。即使在缺乏实体规则的情况下，完善的程序法也可以为各方提供一个公平的解决平台，还可以通过灵活的设计来适应数字贸易的快速变化和规则变化，通过特定的程序安排引导和鼓励各方通过协商合作解决争端。在实体规则缺位的情况下，程序法可以通过一些补充措施来缓解争端解决的困难。例如，设立专家咨询机制，为争端解决机构提供专业的技术意见和法律建议，帮助其更好地理解 and 处理争端。因此，程序法具有其独立存在的价值，在实体法不足的情况下，完善数字贸易争端解决程序仍具有相当的积极意义。

## （三）兼顾数字贸易争端解决的中心化与去中心化

长期以来，多边规则与区域安排重叠所带来的制度复杂性，一直是国际贸易体系的重要特征。<sup>〔33〕</sup>

〔32〕 参见赵春蕾：《美欧自由贸易协定下劳工争端解决机制的范式分析与经验借鉴》，载《国际经济法学刊》2022年第4期。

〔33〕 See Karen J. Alter & Sophie Meunier, *The Politics of International Regime Complexity*, 7 Perspectives on Politics 13 (2009).

全球数字贸易争端解决机制同样面临着中心化与去中心化两种不同模式的选择和发展方向。

中心化的争端解决模式，是指争端裁判权力集中于某一常设的争端解决机构，该机构选聘固定的裁判人员，适用统一的程序规则，形成体系化和一致性的争端解决体系。此种模式下，争端解决参与主体受制于相同程序规则的严格约束，对程序的干预或选择空间较小。在国际贸易法领域，WTO 争端解决机构具有突出的中心化特征，构建了强制管辖权和严格的裁判程序规范，成员方在“一揽子协定”下的利益受到损害时，只能请求 WTO 争端解决机构对其他成员方的贸易措施合法性作出判断，争端解决机构通过上诉机制对初审专家组的法律适用错误进行纠正。中心化的优势在于统一性和权威性，劣势则在于灵活性不足，例如，WTO 的规则制定和修改程序较为复杂，难以及时反映数字贸易的新需求。

去中心化的争端解决模式，则是指某一国际法领域内不存在统一的裁判机构，裁判权力相对分散，由数量众多且彼此独立的临时性裁判主体基于争端方的特殊约定，根据较为灵活的程序规则对争议进行裁决的机制。在此模式下，争端解决当事方对于程序问题享有较高的意思自治空间。区域贸易协定多元化的争议解决机制具有明显的去中心化特征，其优势在于灵活性和适应性。例如，区域贸易协定能够及时调整其数字贸易规则以适应新兴技术的发展，可根据区域内的产业特点和经济结构制定针对性的数字贸易规则。其劣势则在于多元化机制导致的规则碎片化，相互冲突和竞合的现象时有发生，增加了贸易成本和不确定性。

数字贸易争端解决机制的完善，需要平衡中心化和去中心化模式各自的利弊。中心化模式有助于构建具有一致性和稳定性的规则体系，在争端解决过程中更加系统性地处理数字贸易发展过程中的普遍问题，弥合法律解释分歧，从而促进人类经济社会的有序发展，符合国际社会对于秩序、稳定与和谐的期待。去中心化模式则更能反映数字贸易发展不平衡的现实需要，更能适应数字技术的快速发展并进行相应的规则创新。鉴于当前国际社会在数字贸易定义、数据跨境流动、个人数据保护等数字贸易议题上仍存在较大分歧，短期内难以形成统一的全球数字贸易规则框架，去中心化的区域性数字贸易争端解决机制仍有继续存在和发展完善的必要，而改革并完善以 WTO 为中心的 digital 贸易争端解决机制，则将作为国际社会的长期奋斗目标。

## 五、结 语

国际争端解决是维护和促成国际秩序调整以及生成和发展国际法的重要途径。与国内法律制度中存在以国家公信力为后盾的司法裁决机构相比较，国际法体系中是否存在某种意义上独立公正、具有可执行力的司法性裁决机制成为国际法是否具有“法”的特性的重要衡量尺度。<sup>〔34〕</sup>数字化带来贸易形态的改变，要求在规则和争端解决层面作出回应。当前困扰全球数字贸易发展的最大问题，主要在于国际社会对此缺乏统一的系统化安排，突出表现为 WTO 改革的滞后和区域贸易协定的碎片化，导致数字贸易争端陷入“规则真空”与“机制失灵”的双重困境，需要国

〔34〕 参见赵宏：《从“契约”到“准司法”——国际争端解决的发展进路与 WTO 争端解决机制改革》，载《清华法学》2023 年第 6 期。

际社会通过规则创新、技术赋能和协作治理加以解决。在多边层面，各国应加快推进 WTO 数字贸易规则的谈判进程，明确数字贸易的定性标准和解释原则，充分考虑数字贸易特殊性，推动构建与数字时代相适应的高效、公平且具有普遍约束力的数字贸易争端解决机制，为全球数字贸易的健康发展提供坚实的制度保障，维护全球贸易秩序的稳定与公平。在区域层面，数字贸易规则应朝着开放、包容、创新、安全的方向发展，既要促进数字经济的增长，也要解决隐私、安全和发展不平衡等问题，还应重视不同协定间的规则协调与兼容，为促进数字贸易规则走向多边化和实现数字贸易争端解决中心化充分发挥其“垫脚石”作用。

---

**Abstract:** Compared with traditional trade in goods and services, digital trade and its dispute resolution exhibit distinctive characteristics. The effectiveness of the WTO dispute settlement mechanism is limited by outdated rules and partial applicability. Although regional trade agreements (RTAs) endeavor to establish new rule sets, they suffer from insufficient coordination and enforcement, hindering the emergence of a unified framework. At present, digital trade disputes are ensnared in a dual dilemma of “rule vacuum” and “mechanism failure”. Developing an efficient, fair, and universally binding mechanism for resolving digital trade disputes has thus become an urgent challenge for the international community. Given the particularities of digital trade, there is a need to design differentiated dispute resolution procedures. Such a mechanism should both reflect the regulatory constraints of digital disciplines and accommodate the adaptability and flexibility of the development of digital economy rules. In the absence of a globally unified set of substantial rules for digital trade, it is feasible and necessary to prioritize the development of dispute settlement procedures. The WTO multilateral mechanism and the diversified dispute settlement mechanisms of RTAs have their respective advantages and drawbacks. Diversification currently dominates, but multilateralism remains the envisaged future direction.

**Key Words:** digital trade, dispute resolution, world trade organization, regional trade agreements

---

(责任编辑：肖 芳)